

1502915-57.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Cesar do Nascimento

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Fusão da figura do usuário com a do traficante que faz preponderar a última. Condenação acertada. Concessão do redutor na fração de metade. Possibilidade de fixação do regime aberto. Réu primário e hediondez do chamado tráfico privilegiado que foi afastada pelo pleno do E. STF. Substituição da pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

5ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502915-57.2021.8.26.0536 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 18 de janeiro de 2021, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. FERNANDO CESAR DO NASCIMENTO. Eu, Nathalie Cristina Cardoso, Assistente Judiciário, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502915-57.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2240564/2021 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 20030181 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS,

1273/21/010 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 2240564 - 01º D.P. SANTOS, 1273/21/010 -

01º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX PRADO MORAES PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

ALEX PRADO MORAES PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 02 de setembro de 2021, por volta das 21h10min, na Rodovia Manoel Hypolito do Rego, nº 246, nesta cidade e Comarca, trazia consigo e guardava, tinha em depósito e transportava, um tijolo de aproximadamente 998,4

gramas maconha para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (págs. 66/69).
O acusado foi preso em flagrante (págs. 01/19).
Termo de exibição e apreensão (pág. 07) e auto de constatação preliminar (pág. 08).
Certidão e folha de antecedentes (págs. 17/19).
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (págs. 33/38).
Laudo pericial (págs. 58/60) e do IML (págs. 83/86).
O réu foi notificado e apresentou, por meio de Defensor, defesa preliminar (págs. 89/94).
A denúncia foi recebida em 21 de outubro de 2021 (págs. 95/96).
Designada audiência de instrução e julgamento (pág. 109), a prisão preventiva foi mantida (pág. 146).
Em audiência, foram ouvidas as testemunhas da acusação e defesa, sendo mantida a prisão preventiva do acusado e designada audiência em continuação para oitiva dos policiais arrolados, em gozo de férias (págs. 152/153 e 173). Na audiência de instrução em continuação foi coletada a prova oral faltante, inclusive interrogatório, e encerrada a instrução, conforme termo e mídia nos autos (págs. 176/178).
O Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a procedência da denúncia alegando estarem provadas autoria e materialidade dos delitos, sem a aplicação do benefício do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois fazia do crime seu meio de vida e estava envolvido com atividades criminosas, sem direito a substituições e regime inicial fechado.
A Defesa, por sua vez, em resumo, sustentou que a aquisição da droga se deu para uso pessoal do acusado e seus amigos, requerendo a parcial procedência da acusação, com a fixação da pena no mínimo legal, eis que ele é réu primário, com atenuação em razão da confissão do acusado, com aplicação do benefício do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas e redução na proporção de 2/3, com fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
Subsidiariamente, caso fixado o regime semiaberto, requer a concessão da liberdade provisória.
É o relatório necessário.
À fundamentação e decisão.
Tem-se, in casu, acusação do cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, que vem assim previstos na Lei nº 11.343/2006 – Lei Antidrogas:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

A ação é procedente.

Consigno, inicialmente, que “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

A materialidade vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (págs. 01/15), pelo auto de exibição e apreensão de pág. 07, pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente de pág. 08, pelo laudo toxicológico de págs. 58/60 e pela prova oral coligida aos autos.

Do mesmo modo, inequívoca a autoria.

Conforme se extrai do interrogatório do acusado, oportunidade em que disse que a acusação é verdadeira. Que fuma maconha desde menor de idade. Que foi até a biqueira da Lola pra pegar a droga e que ia dividir com outros 3 amigos. Cada um dos dois amigos deu quatrocentos reais e ele trezentos, sendo cem para o uber. Como

deu a menor parte, foi o responsável por buscar. Ia dividir em três pedaços. Sempre pegava só para ele, de cem a cento e cinquenta reais. Essa foi a primeira vez que foi buscar essa quantia. Ia durar em média uns seis meses, para mais. Nunca forneceu a outras pessoas, nem vendia. Questionado do motivo pelo qual não disse aos policiais que tinha adquirido a droga para dividir com os amigos, disse que ficou angustiado e não veio na cabeça de falar na hora. Disse que esses outros dois amigos não quiseram vir depor. Forneceu para a irmã e para o advogado o nome deles. Não paga pensão para o filho, porque mora junto com ele. Mora com ele e com a mãe. Mora ele, a esposa, o filho e a avó. Fazia eventos na casa das pessoas, como sushiman, pela Tigo Sushi Bar. Ganhava cento e vinte reais por evento, por mês não sabe dizer. Fazia mais de final de semana, de sexta, sábado e domingo. Não consegue precisar quantos, porque não era uma coisa certa.

A testemunha Fábio, em Juízo, disse que conhece o acusado da cidade e já fez corrida pra ele, para esposa e para o filho. A testemunha mora em Bertioga e o acusado e a esposa também. No dia dos fatos, o acusado ligou para ele e perguntou se ele podia buscá-lo no Guarujá por cem reais. Ele aceitou a corrida. Buscou ele em Itapema e estava voltando para Bertioga com ele quando foi parado na polícia rodoviária. Ele mostrou os documentos, abriu o porta-malas e mostrou, a pedido dos policiais. Algemaram o depoente e colocaram ele na viatura. Disseram que o passageiro estava levando um tijolo de maconha, mas não sabe, só viu um negócio enrolado em uma sacola. Colheram o depoimento dele na delegacia e ele foi liberado. Ele não sabe onde estava a sacola, não viu. Só mostraram quando ele estava algemado. Não viu ele entrar com sacola, viu ele entrar com uma garrafinha de cerveja, mas não prestou muita atenção porque nesse dia tinha trabalhado muito no consultório odontológico. Não observou se ele entrou com a sacola. Foi a única corrida que ele fez no dia e não foi por aplicativo, foi direto pelo celular. Não fez nenhuma outra corrida, então essa sacola não poderia ser de outro passageiro. Não conversou com o acusado sobre esses fatos. Não sabe com o que o acusado trabalha. Já tinha feito corridas para ele, esposa e filhos, levando até a casa da esposa, ou até a casa dele, mas poucas vezes e corridas curtas dentro de Bertioga. Mora no mesmo bairro do acusado desde que nasceu. Conhece ele de vista há muito tempo, mas não sabe há quanto tempo ele mora na cidade. Nunca ouviu comentários de que ele vende drogas.

A testemunha Henrique, em Juízo, disse conhecer o acusado desde a adolescência, que já usou maconha com ele e nunca ouviu falar que ele vendesse drogas. Quando convivia com ele, ele sempre fumou muito. O acusado sempre buscava ter uma quantidade maior de maconha, não gostava de depender de ficar indo atrás de droga, ir em boca de fumo, ele não podia ficar sem porque ficava insuportável. O depoente mora em Santos há 12 anos. Mesmo morando em Santos, continuou tendo uma relação próxima com Bertioga, só se afastou mais recentemente. Só agora que esse vínculo com o acusado diminuiu um pouco. Se afastou mais há uns dois anos. Antes tinha época que ia todo final de semana, às vezes ia menos. O Alex não sabia o que estava fazendo, mas antigamente fez uber, fez bico em alguns negócios de amigos. Já foram guarda-vidas juntos. Na atualidade, a última atividade que se lembra que conversaram foi de uber e na cozinha. Não sabe dizer há quanto tempo, mas já faz um tempo. Na atualidade, não sabe se ele tem trabalho. Não sabia que ele foi preso em Guarulhos com droga também.

A testemunha David, Policial Militar, disse que estavam fazendo uma operação quando avistaram o veículo Fox, foi dado sinal de parada que foi atendido pelo motorista. Foi feita busca pessoal em ambos e nada foi encontrado, mas em busca veicular, na parte de trás, no assoalho, onde estava sentado o acusado, tinha um tijolo de maconha. Questionado, o acusado disse que adquiriu no Guarujá para uso próprio e pagou mil reais. Diante disso, ele foi preso. O motorista do veículo disse que estava fazendo serviço de Uber e confirmou que a droga era do acusado. Questionado, ele insistiu que apesar da quantidade, era para uso próprio. Não se recorda se ele disse que congelaria.

A testemunha Robson, Policial Militar, disse que estavam fazendo uma operação quando avistaram o veículo Fox, foi dado sinal de parada que foi atendido pelo motorista. Foi feita busca pessoal em ambos e nada foi encontrado, mas em busca

veicular, na parte de trás, no assoalho, onde estava sentado o acusado, tinha um tijolo de maconha. Questionado, o acusado disse que adquiriu no Guarujá, na biqueira da Lola, para uso próprio. O motorista do veículo confirmou que a droga era do acusado. Questionado, ele insistiu que era para uso próprio. Disse que pagou mil reais. Não se recorda se ele disse que trabalhava.

Como é bem sabido, a lei não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação.

Nesse sentido, registrem-se os seguintes paradigmas:

“PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.”

(Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.).

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.”

(HC 73518, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).

“A condição de a testemunha ser Policial não a torna impedida ou suspeita para depor, devendo-se conferir à sua palavra a necessária credibilidade, decorrente da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral”. (RJTACRIM 48/228).

Ainda:

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Impossibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos. Circunstâncias da apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Fusão da figura do usuário com a do traficante que faz preponderar a última. Condenação acertada. Concessão do redutor na fração de metade. Possibilidade de fixação do regime aberto. Réu primário e hediondez do chamado tráfico privilegiado que foi afastada pelo pleno do E. STF. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e outra de multa. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0001618-51.2017.8.26.0594; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - Artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/03 - Sentença condenatória - Recurso defensivo - Absolvição por fragilidade probatória - Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra dos policiais militares - Validade - Precedentes - Réu encontrado na posse da arma de fogo - Condenação mantida - Dosimetria penal - Inobservância do sistema vicariante - Readequação - Necessidade - Reconhecimento da atenuante da confissão - Atenuante da menoridade relativa não restou caracterizada, uma vez que o réu já possuía vinte e um anos na data do fato - Substituição por restritivas de direito - Impeditivo legal - Regime prisional inicial semiaberto - Adequado à espécie - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0000420-09.2015.8.26.0542; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019).

À solução do feito, ainda, consigno que o réu foi preso em flagrante, fato que, segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra *Do Flagrante Delito*, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor: "Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49). De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

"PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento: 59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente." (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205).

Cumprе salientar que, para haver o crime de tráfico, não é necessário que o acusado seja preso no ato da venda da mercadoria proibida (confira-se o artigo 33 da Lei Antidrogas). Para a caracterização de delito de tráfico deverá ser observada a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem com as circunstâncias da prisão, a conduta do agente e seus antecedentes, nos termos do artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006. Como se extrai, o acusado não nega que foi o responsável por comprar e que trazia consigo a droga apreendida, sustentando, no entanto, que não o fazia para fins de comércio, mas para compartilhar com outros dois amigos sem objetivo de lucro, em uma tese defensiva que objetivava a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 33, §3º, do Código Penal.

De proêmio, destaco que, ainda que o acusado seja usuário de droga, como afirma em seu interrogatório e ratifica a testemunha Henrique, é certo que a mera condição de usuário não exclui automaticamente a traficância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a desclassificação para a figura tipificada no art. 28 da Lei 11.343/06, a fixação da pena-base no mínimo e a aplicação do redutor. Impossibilidade. Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas. Provas dos autos sustentam de forma clara e indubitosa a condenação. Finalidade de mercancia caracterizada. A simples condição de usuário não exclui automaticamente a traficância. Condenação por tráfico era mesmo de rigor. Dosimetria não comporta reparos. Na primeira fase, cabível a fixação das basilares acima do mínimo, diante dos comprovados maus antecedentes. Ao final, impossível aplicar o redutor. Regime fechado proporcional e necessário à hipótese em comento. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Recurso

improvido.

(TJSP; Apelação Criminal 1503302-09.2020.8.26.0536; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cubatão - 2ª Vara; Data do Julgamento: 07/01/2022; Data de Registro: 07/01/2022)

Ademais, sua versão de uso compartilhado isolada dos autos e desprovida de qualquer elemento probatório capaz de corroborá-la.

Com efeito, não há provas do ajuste entre os amigos acerca da aquisição da droga, e tampouco compareceram estes em Juízo com o propósito de ratificar a versão do acusado de que teriam contribuído para a aquisição da droga e fariam o uso compartilhado dela.

Vale destacar que o acusado não possui emprego fixo e alega que à época dos fatos fazia "bicos" em eventos aos finais de semana, auferindo cerca de cem a cento e cinquenta reais por dia, quando tinha evento, o que não ocorria em uma frequência certa, o que, aliado à absoluta ausência de provas do compartilhamento da droga, leva à conclusão de que a quantidade de droga (quase um quilo) e o valor por ela empregado (mil reais) é incompatível com a sua aquisição apenas para uso próprio. Portanto, tudo força à conclusão de que o acusado trazia consigo (confira-se o disposto no artigo 33 da Lei de Drogas) drogas para o comércio, pois a quantidade de droga apreendida e valor por ela empregado, aliado à prova testemunhal e confissão parcial do acusado, levam à certeza de que o réu é traficante das drogas apreendidas, impondo-se, pois, a condenação.

Passo, então, à dosimetria da pena, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal e 42 da Lei Antidrogas, obedecendo ao critério trifásico.

Em fundamentação à aplicação das penas, observo que o réu não possui maus antecedentes (Súmula 444 do C. Superior Tribunal de Justiça). Ademais, os autos não fornecem elementos de convicção seguros sobre os motivos e circunstâncias. A personalidade e a conduta social não são especialmente reprováveis. A culpabilidade e as consequências da conduta já foram mensuradas no estabelecimento elevado dos parâmetros abstratos de pena no tipo penal incriminador.

Há que se considerar dentre as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei de Drogas, de forma destacada, a quantidade expressiva de droga apreendida (quase um quilo de maconha), que enseja aumento de pena em 1/6 (um sexto).

Portanto, fixo a pena-base do condenado acima do mínimo legal, aumentando-a em 1/6 (um sexto), resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, inexistem agravantes a serem consideradas e tampouco é devida a aplicação da atenuante de confissão espontânea, tendo em vista que o réu reconheceu apenas a propriedade das drogas, mas não a traficância, de sorte a incidir a Súmula 630 do C. Superior Tribunal de Justiça, que possui a seguinte redação:

"Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."

Com isso, a pena intermediária permanece de 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento. De outra parte, quanto à presença de causas de diminuição, primeiramente, reputo como constitucional a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, motivo pelo qual a aplicarei no presente caso, como nos demais.

De fato, foi estabelecido por esta disposição normativa que a pena pode ser diminuída, de um sexto a dois terços, ao traficante de drogas que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: seja primário; seja portador de bons antecedentes; não se dedique às atividades criminosas; e não integre organizações criminosas, entendimento aplicado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, senão vejamos:

"Entorpecentes - Absolvição - Insuficiência de provas - Não ocorrência - Conjunto probatório seguro para uma condenação. Pena - Tráfico de entorpecente - Réu primário e com bons antecedentes - Redução da pena com o aumento do redutor previsto no § 4º do artigo 33 caput, da Lei 11.343/06 - Impossibilidade, em razão da quantidade da droga apreendida. Entorpecente - Tráfico - Pena - Réu primário e com bons antecedentes - Aplicação do § 4º do artigo 33 caput, da Lei 11.343/06 - Possibilidade - Inconstitucionalidade - Não ocorrência - Forma de individualização da pena, prevista na própria Constituição. Entorpecente - Pena ? Redução da pena ? Benefício do § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06 - Possibilidade ? Princípio da proporcionalidade observado - Apelações do Ministério Público e do réu não providas."

(TJSP, Apelação 990090422181, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 25/08/2009, reg. 18/09/2009).

"Entorpecentes - Conjunto probatório hábil a demonstrar apreensão de entorpecente destinado à entrega ao consumo de terceiros - Prova suficiente para a condenação do apelante - Réu primário com bons antecedentes - Inviável a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 - Imperiosa a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo - Penas dosadas em excesso - Recurso parcialmente provido."

(TJSP, Apelação 990081696835, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 13/08/2009, reg. 17/09/2009).

Na espécie, o postulado preenche tais requisitos, nominalmente por ser primário e não existir indícios que participe de organizações criminosas de qualquer espécie. Como disse acima, e por coerência, a quantidade de droga apreendida é suficiente à subsunção dos fatos ao delito de tráfico, mas não à conclusão de que o réu tinha habitualidade no tráfico e, tampouco, à não-aplicação da causa de diminuição da pena.

Para que não se aplicasse a causa de aumento deveria haver nos autos a plena comprovação, ou ao menos fatos que levassem a essa conclusão, de que o réu se dedicava à atividade criminosa, sendo certo que a folha de antecedentes do acusado não apontou qualquer outro indicativo nesse sentido.

Assim sendo, preenchidos os requisitos do aludido parágrafo 4º, reduzo a pena em seu grau mínimo, qual seja, 1/6 (um sexto), considerando, a tanto, a elevada quantidade de droga apreendida, estabelecendo em definitivo a pena privativa de liberdade do condenado em 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão mais 486 dias-multa.

Anote-se que não constitui bis in idem a avaliação, novamente nesta fase, da quantia de droga apreendida em poder do acusado, conforme precedente do C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

"Habeas Corpus. Penal. Crime de Tráfico ilícito de entorpecentes. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da nova lei de tóxicos. Possibilidade de aplicação caso o apenado satisfaça os requisitos legais. Cisão de dispositivos legais. Manutenção. Regime fechado. Inviabilidade. São requisitos para que o condenado faça jus à causa de redução da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Reconhecidas tais circunstâncias, a quantidade da droga, por si só, não tem o condão de impedir a aplicação da minorante, sob pena de se criar condição não prevista em lei. Precedentes. O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com predominância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33. "

(STJ, HC 0043900-6/2009, 6ª Turma - Ministro Vasco Della Giustina, j. 01/09/2011, DJe. 26/09/2011).

Em reforço à pena até aqui aplicada:

"Apelação - Tráfico de drogas (art. 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06) - Absolvição pretendida - Insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Negativa do recorrente isolada no conjunto probatório - Apreensão em poder do acusado de 13 porções de 'crack' ? Testemunhos policiais seguros e coesos acerca das circunstâncias da diligência - Validade ? Condenação de rigor - Desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 - Inocorrência - A quantidade e qualidade do entorpecente apreendida em poder do acusado e a forma de acondicionamento revelam a traficância - Pena- base fixada no mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais favoráveis ostentadas pelo agente - Exasperação da reprimenda em razão do reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06 ? Traficância exercida com o objetivo de atingir adolescentes - Incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo, ante o preenchimento dos requisitos necessários - Substituição penal incompatível, nos termos do art. 44, da Lei nº 11.343/06 - Regime inicial de cumprimento de pena ? Manutenção - Em razão da vigência da Lei nº 11.464/07, de rigor a aplicação do regime de cumprimento de pena no inicialmente fechado, observando os critérios nela estabelecidos. Recurso improvido." (TJSP, Apelação 990100233793, 4ª Câmara de Direito Criminal, rel. Salles Abreu, j. 08/06/2010, reg. 25/06/2010).

Os dias-multa terão valores mínimos legais, devido à ausência de prova da capacidade econômica do réu.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena aplicável, revendo meu posicionamento anterior, entendo possível a aplicação de regime inicial diferente do fechado, frente ao julgamento de inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990 proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal no HC 111844/SP e HC 112195/SP, bem como fato de o E. STF, no HC 118533, não ter considerado o tráfico privilegiado como crime hediondo.

Deveras, foi possível apurar em pesquisa que existe divergência entre as Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal do Estado de São Paulo, sendo que cerca de metade delas vêm aplicando o entendimento consagrado pelo E. Supremo Tribunal Federal. Exemplificando, seguem ementas que auxiliaram na adoção da presente conclusão: APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de DROGAS - Sentença condenatória - Recurso defensivo desprovido por esta E. Câmara - Interposição de Habeas Corpus pela defesa perante o Superior Tribunal de Justiça - Fixação do regime inicial aberto por aquela Corte Superior e determinação para que este Tribunal substitua a pena privativa de liberdade - Súmula 512 do STJ cancelada - Figura privilegiada que não mais se reveste de hediondez - Precedente do Pleno do STF - Pena inferior a 04 anos - Inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - Substituição da pena corpórea por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária - Exegese do art. 44 do CP - Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 0002636-27.2015.8.26.0126; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018) (grifei)

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. Tratando-se de traficância de 50 gramas de drogas ilícitas, praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, faz-se de rigor a assistência máxima da causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, com a substituição por alternativas da pena privativa de liberdade que, se o caso, será inicialmente cumprida no regime prisional aberto.

(TJSP; Apelação Criminal 0041225-20.2018.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/07/2019; Data de Registro: 26/07/2019) (grifei)

Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória (artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06). Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para firmar a responsabilidade penal do acusado. 2. Sanção que não comporta alteração. Quadro excepcional que

autoriza a manutenção do regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0001722-16.2017.8.26.0603; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Buritama - 2ª Vara; Data do Julgamento: 04/04/2019; Data de Registro: 08/04/2019) (grifei)

Assim, em razão sobretudo da primariedade, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Pela quantidade de pena imposta, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal) ou a suspensão da pena (artigo 77 do Código Penal).

Dispositivo.

Ante o exposto e pelo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu ALEX PRADO MORAES PEREIRA, qualificado nos autos, por incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa no valor mínimo legal.

Por fim, considerando a fixação do regime inicial semiaberto, de rigor a concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto manter a prisão preventiva, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, representaria a imposição de um regime prisional mais gravoso daquele ora estabelecido.

Nesse sentido, destaca-se que, em julgados recentes, o E. Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se considerou ser a prisão preventiva incompatível com o regime semiaberto de cumprimento de pena, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTES SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 185181 AgR, Relator(a): Min. CÂRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020)

HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PENA CAUSA DE DIMINUIÇÃO TRÁFICO DE ENTORPECENTES ADEQUAÇÃO. Ausente demonstração de dedicação do paciente a atividades criminosas, surge adequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTO TÍTULO CONDENATÓRIO REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A previsão do regime semiaberto para o cumprimento da pena, mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, no que a manutenção da custódia preventiva, cujo cumprimento dá-se no fechado, implica a imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a do título condenatório. (HC 180016, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020) (grifei)

APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, na forma tentada. Recursos defensivos. Preliminar de nulidade. Violação ao princípio da individualização da pena. Inadmissibilidade. Sistema trifásico devidamente observado em favor do acusado MAICON. Preliminar rejeitada. Mérito. Autoria e materialidade bem demonstradas. Réus confessos. Dosimetria. Pleito de redução da fração de diminuição relativa ao reconhecimento da forma tentada do delito. Possibilidade. Acusados que percorreram iter criminis intermediário. Pedido de afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Cabimento. Arma apreendida que estava desmuniada. Ausência de potencial lesivo. Penas redimensionadas. Abrandamento do regime prisional fixado em desfavor dos apelantes.

Cabível. Quantum da pena e demais circunstâncias do delito que autorizam a fixação do regime inicial aberto aos acusados MAICON e ÍTALO, e do regime inicial semiaberto ao apelante CARLOS, em razão da reincidência por ele ostentada. Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade. Revogação da prisão preventiva dos apelantes. Regimes prisionais fixados incompatíveis com a prisão preventiva. Entendimento do E. Supremo Tribunal Federal. Recursos parcialmente providos.

(TJSP; Apelação Criminal 1500054-83.2021.8.26.0153; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cravinhos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021) (grifei)

Assim sendo, REVOGO a prisão preventiva do réu, autorizando o recurso em liberdade (artigo 387, §1º, do Código Penal). Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Taxa judiciária devida na forma do artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/2003, observadas as regras da Lei nº 1.060/1950, se o caso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, cumprindo-se as demais formalidades legais e após, arquivem-se.

P.I.C.

Santos, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA